

1502342-41.2020.8.26.0540
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella
Comarca: Mauá
Foro: Foro de Mauá
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 28/07/2022
... Justiça do Estado de São Paulo:

"Apelação- Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa- Pedido para que o réu possa recorrer em liberdade prejudicado pelo presente julgamento. Condenação mantida. Apreensão de 20 porções de maconha e 61 porções de cocaína- Conjunto probatório seguro e coeso. Dosimetria fixada com rigor- Pena fixada no mínimo legal - Pedido de compensação entre ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mauá
Foro de Mauá
2ª Vara Criminal
Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502342-41.2020.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502342-41.2020.8.26.0540
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
REGIANE DE SOUZA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

REGIANE DE SOUZA foi denunciada por incursão no caput do artigo 155 do Código Penal.

Narra a inicial acusatória que, no dia 23 de dezembro de 2020, por volta das 14h45, na Avenida Presidente Castello Branco, 1409, Jardim Zaíra, nesta cidade e comarca de Mauá, a denunciada subtraiu, para si, uma camiseta masculina de cor azul, marca Nike, e uma camiseta masculina de cor vermelha, marca Puma, avaliadas no total de R\$ 100,00 (auto de fls. 75/76), pertencentes ao estabelecimento comercial Mega Outlet Mauá.

Recebida a denúncia, o feito foi suspenso nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (fl. 115).

Posteriormente, a ré foi citada (fl. 209) e apresentou resposta à acusação.

Durante a instrução, a testemunha arrolada pelas partes foi devidamente inquirida. Por fim, interrogou-se a ré.

Em memoriais finais, o Ministério Público requer a parcial procedência da ação penal, reconhecendo-se a tentativa, enquanto a Defesa pleiteia a absolvição pela insignificância ou atipicidade da conduta. Subsidiariamente, busca a aplicação da pena no patamar mínimo, com o reconhecimento da confissão, da tentativa e da forma privilegiada do delito, além da fixação de regime penitenciário aberto e a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

Procede em parte a acusação.

Comprovou-se a materialidade pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 08-10), auto de exibição e apreensão (fls. 11-2) e prova oral colhida.

A autoria é inconteste.

A ré foi devidamente interrogada em solo policial e em juízo (fl. 06 e mídia digital).

A representante da vítima Caroline, na fase antejudiciária, afirmou que (sic) "vi a indiciada aqui presente na referida fila, já para pagar um boné que trazia na mão, quando vi a indiciada abrir a bolsa e pegar a carteira, ocasião em que vi roupas e a etiqueta da loja dentro da bolsa. Observei que a indiciada quitou apenas o boné e as roupas ocultas na bolsa não pagou. Diante do constatado, resolvi avisar o segurança do local, sempre acompanhando a indiciada, que entrou novamente para o interior da loja com a sacola que continha o boné pago. Dirigiu-se a mim e perguntou sobre a numeração de um chinelo e se afastou de mim. Neste momento, avisei o segurança e este resolveu abordá-la, pediu-se para a indiciada abrir a bolsa, sendo que esta ficou nervosa e perguntou o porquê, ocasião em que foi-lhe perguntado se havia mercadoria na bolsa dela, quando a indiciada respondeu que já havia "dispensado", ocasião em que pediu-se novamente "por favor" para que ela abrisse a bolsa dela, quando acatou o pedido e abrindo a bolsa, retirou de seu interior as duas camisetas, avaliadas em R\$50,00 cada. Surpreendida, a indiciada pediu que ela fosse liberada e prometeu não furtar mais, contudo o gerente solicitou o concurso policial" (fl. 05).

Em juízo, asseverou que uma funcionária visualizou a ré guardando as camisetas na bolsa, motivo pelo qual ficou acompanhando seus movimentos e aguardando ela deixar a loja. No caixa, a acusada apenas pagou pela compra de um chinelo, motivo pelo qual o dono da loja chamou-a e pediu para ela retirar as mercadorias guardadas na bolsa. Esclareceu que a ré foi abordada no caixa e não chegou a sair do estabelecimento (mídia digital).

O gerente Ronaldo, na mesma linha que Caroline, narrou que (sic) "estava no local a trabalho auxiliando a funcionária do caixa, quando a indiciada aqui presente estava na fila com mercadoria na mão, não observei qual mercadoria, cuja mercadoria ela pagou no caixa. A vendedora Carol logo após procurou-me e disse que percebeu que a indiciada e cliente aqui presente, na ocasião ocultava mercadoria furtada da loja, dentro da bolsa, que não foi quitada no caixa. Sabendo do que Carol havia visto, fui em direção à suspeita que saiu da loja e atingiu a calçada, a qual percebendo retornou até o interior da loja, ocasião em que juntamente com Carol, foi solicitado à indiciada que abrisse a bolsa, porém a abordada disse que "já tinha dispensado a mercadoria", contudo insisti em ver o interior da bolsa da suspeita,

quando ela abriu a bolsa, foi constatado a existência de duas camisetas da loja, que a suspeita retirou e entregou na mão da Carol" (fl. 04).

Os policiais militares chegaram ao estabelecimento após a detenção da acusada e o PM Fabiano historiou que, informalmente, Regiane confessou o furto das camisetas (fls. 02-3).

Ao final da instrução, a condenação é medida de rigor.

Não há que se falar em insignificância da conduta, tratando-se de acusada multirreincidente específica (certidão de fls. 35-8), a descortinar uma personalidade voltada para o crime, de tal arte que sua conduta merece uma reprimenda penal, sem o que não seria reprovada adequadamente pela ordem jurídica, num panorama que representaria um estímulo ao cometimento de futuras infrações penais. Neste diapasão, assentou o Supremo Tribunal Federal:

"A reincidência, apesar de tratar-se de critério subjetivo, remete a critério objetivo e deve ser excepcionada da regra para análise do princípio da insignificância, já que está sujeita a interpretações doutrinárias e jurisprudenciais ou a análises discriminatórias. O criminoso reincidente apresenta comportamento reprovável, e sua conduta deve ser considerada materialidade típica". (HC nº 97.722, Rel. Min. Cármen Lúcia, grifo nosso).

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DESCABIMENTO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. Esta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reincidência específica e reiteração da conduta delitiva. 3. Habeas Corpus não conhecido. (STJ, HC 507090 / MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 28/05/2019, DJe 07/06/2019 - grifo nosso).

Sobre o tema, oportuno trazer à baila a brilhante ponderação do ilustre Desembargador Dr. Corrêa de Moraes: "(A) Alegadamente construída com propósitos liberais, a tese do 'crime de bagatela' nada mais representa, em última análise, que a 'camuflagem teórica de uma distorção ideológica': seria axiologicamente inócuo e até mesmo 'politicamente correto' subtrair coisa alheia móvel, porque a propriedade não deveria merecer tutela jurídica, o que, 'de lege lata', é um absurdo e, 'de lege ferenda', uma leviandade. Para o caso em que 'é de pequeno valor a coisa furtada', o legislador reservou as mercês do § 2º do art. 155. Nada além disso. (B) A 'Teoria da Bagatela' é, em última análise, a 'bagatela da teoria', pura extravagância teórica, idealizada para assegurar a impunidade do infrator. Para a mão que ofende, a lesão é sempre de 'bagatela'. Mas é sempre dolorosa para o rosto que a suporta. Para a mão que furta, a lesão patrimonial é sempre de bagatela. Mas é sempre aflitiva para o bolso desfalcado. Nesse relativismo pendular, fico com o sujeito passivo. É necessário ter bem presente no espírito que a reprovação/punição da conduta em exame (e de comportamentos análogos) tem conteúdo ético, que abstrai do peso econômico da coisa subtraída. O que se reprova/pune, com total independência do valor circunstancial da coisa sobre a qual recai a ação é o desvalor, a negatividade axiológica da própria conduta. O preceito subjacente à previsão repressiva do art. 155 é 'não furtarás' nem isto nem aquilo, nada importando se isto vale muito e aquilo vale pouco. Em tais condições, o diminuto peso econômico da coisa não pode ser levado à categoria de causa excludente da ilicitude". (TJ-SP - APR: 00020385820178260270 SP 0002038-

58.2017.8.26.0270, Relator: Walter da Silva, Data de Julgamento: 30/05/2019, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/06/2019).

Afasta-se, também, a tese defensiva quanto a prática de meros atos preparatórios impuníveis. A ré pegou as camisetas, guardou-as em sua bolsa e tentou passar pelo caixa, praticando, assim, atos executórios e expondo o bem jurídico protegido pela norma penal a perigo real, apenas não consumando o crime pela intervenção dos funcionários do local. Neste sentido o e. Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO (ART. 155, § 1º E § 4º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓD. PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO REVELA A PRÁTICA APENAS DE ATOS PREPARATÓRIOS E DE COGITAÇÃO. SUSTENTADA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ANIMUS FURANDI. ACUSADO SURPREENDIDO NO INTERIOR DA GARAGEM DA RESIDÊNCIA. TENTATIVA DE FUGA. PRÁTICA DE ATO INEQUIVOCAMENTE EXECUTÓRIO. PROPÓSITO DE ASSENHORAMENTO DE COISA ALHEIA MÓVEL EVIDENCIADO. TENTATIVA DE FURTO CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO PRESERVADA. Se o agente foi surpreendido no interior da garagem da residência da vítima, sendo imobilizado quando tentava transpor o muro da propriedade, não se pode falar apenas em cogitação ou atos preparatórios, porquanto praticou atos que expôs a risco relevante e concreto o bem jurídico protegido, dando assim início à execução do crime patrimonial que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Nesse contexto, se a versão do réu no sentido de que buscava apenas se proteger de uma perseguição estiver completamente dissociada da realidade probatória, não há como afastar o animus furandi, à luz do disposto no art. 156, caput, do Código de Processo Penal. (...) (TJSC, AP Nº 5012037-76.2020.8.24.0018, REL. DES. SIDNEY ELOY DALABRIDA, j. 15 de abril de 2021).

Ainda, o c. Superior Tribunal de Justiça:

(...) Quando o agente penetra no verbo nuclear, sem dúvida, pratica atos executórios. No entanto, comportamentos periféricos que, conforme o plano do autor, uma vez externados, evidenciam o risco relevante ao bem jurídico tutelado também caracterizam início da execução do crime. (...) (REsp 1252770/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 26/03/2015).

Crime impossível também não houve. Sabe-se que mesmo os sistemas de vigilância mais sofisticados não são infalíveis. Com efeito, "não exclui a possibilidade de tentativa, respondendo o agente por ela, quando o meio é relativamente ineficaz, ou seja, quando há uma mínima possibilidade de atingir o resultado" (JÚLIO FABBRINI MIRABETE, Código Penal Interpretado, Atlas, 2005, pág. 185). Essa tem sido a orientação perfilhada pela jurisprudência (STJ, REsp nº 633.656, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca; REsp nº 555.268, rel. Min. Gilson Dipp; REsp nº 598.224, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa; REsp nº 554.233, rel. Min. Laurita Vaz).

Por outro lado, como bem observado pelas partes, necessário o reconhecimento da tentativa.

Após a instrução, apurou-se que a ré não consumou o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, já que foi flagrada na posse da res ainda no interior do estabelecimento comercial.

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria, de rigor a condenação.

Passo à dosagem da pena.

Atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixa-se a pena base da ré 1/6 acima do mínimo legal, pelos maus antecedentes (certidão de fl. 35 - proc. 83124-71.2013), perfazendo 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Sobre a possibilidade de utilização de uma das condenações, transitada em julgado, como maus antecedentes:

“Admite-se a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem”. (STJ. REsp 1946490/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

“(…) é possível que sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como maus antecedentes e a segunda como reincidência, quando distintos os fatos geradores de cada uma.” (HC 344.979/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016).

“Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como maus antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena.” (HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013).

Na segunda etapa, tendo em vista a bi-reincidência específica da acusada (certidão de fls. 35-7 – procs. 712-09.2015 e 98334-89.2018), a pena deve sofrer o acréscimo de 1/2, atingindo 01 ano e 09 meses de reclusão e 16 dias-multa.

A reincidência específica justifica referida fração de aumento, já que maior o desvalor da conduta. Neste sentido, precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça:

“Hipótese em que a fração de 1/3, utilizada para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, lastreou-se no fato de ser o paciente reincidente específico, argumento que se alinha à jurisprudência deste Tribunal Superior. Precedentes” (HC n. 348.170/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2016, DJe de 2/5/2016 – grifo nosso).

“Não há desproporcionalidade na exasperação da pena do paciente em 1/3, pois a instância antecedente destacou sua reincidência específica” (HC n. 331.534/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/10/2015, DJe de 27/10/2015).

“A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, e acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus. É permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, o julgado é claro em reconhecer a reincidência específica do paciente, fato que justifica o incremento da pena em 1/3 (um terço)” (HC nº 257.571/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 18/02/2014).

Ainda, o e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado (artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. artigo 29, “caput”, ambos do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos da vítima. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Réu reincidente específico. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Causa de aumento devidamente constatada. Regime fechado mantido. Recurso não provido. [...] Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e por ser o réu reincidente específico (fls. 115/116) as penas foram acrescidas de 1/3, perfazendo, 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa. [...] Assim, por não entender infundado o aumento da pena, ante as justificativas expostas na r. sentença, - réu reincidente - fica mantida a fração aplicada, como lançada. [...]” (TJSP; Apelação Criminal 0004499-21.2021.8.26.0348; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/06/2022; Data de

Registro: 10/06/2022 - grifo nosso).

Justifica-se, ainda, a não incidência da atenuante da confissão, não espontânea, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão de quem foi presa em flagrante com os objetos subtraídos no interior de sua bolsa não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos. Não fosse suficiente, o presente decisor sequer referiu-se ao interrogatório da ré, portanto, sem infringência à Súmula 545 do STJ.

Sobre a necessidade da espontaneidade da confissão, decota-se trecho do voto do v. acórdão proferido pelo eminente Desembargador Ricardo Dip, no julgamento da Apelação Ordinária 1.390.581-8:

"Em acréscimo, confissão do acusado, houve. Espontânea, contudo, não; a que houve, tem caráter de provocada.

É válida –recurso de votos precedentes–, é válida, repito, ainda após a controvertida Reforma do Código Penal em 1984, esta lição de Roberto Lyra:

'A espontaneidade da confissão não diz respeito, é claro, à sua prestação, em que seria redundante a referência...' (Comentários ao Código Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1958, vol. 2, n. 64).

Não fosse assim, sobeja seria a lei, porque, como disse Fragoso, 'se o agente confessa sob pressão policial, fato, aliás, comum, nenhuma atenuante será aplicável' (Lições de Direito Penal, ed. Forense. Rio de Janeiro, 1994, Parte Geral, n. 345).

Na mesma linha, disse Mirabete: 'Não basta a confissão para a configuração da atenuante; é necessário que o agente, arrependido, procure a autoridade para a confissão, já que a lei não fala em ato voluntário, mas em confissão espontânea' (Manual de Direito Penal, ed. Atlas, São Paulo, 1997, vol. 1, 7.5.6).

Diz José Antonio Paganella Boschi, comentando o disposto na alínea d, inc. III, art. 65, CP: 'Foge ao sentido do texto, portanto, reconhecer a atenuante quando o agente é preso em flagrante e não tem como negar as evidências em torno da autoria ou imputar a responsabilidade pelo fato a terceiro. Inconfundíveis confissão espontânea e confissão voluntária' (Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, ed. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2002, p. 273).

A espontaneidade da confissão –prevista em lei como qualificação necessária do ato confessorio para atuar como causa de atenuação penal– distingue-se da mera voluntariedade da confissão. Não se trata aí do espontâneo como o que procede de um princípio interno juxta naturam agentis, sine deliberatione (Marcelino Zalba), mas do que (disse Cathrein) procedit a princípio interno –ou seja, sem provocação exterior." (TACRIM-SP –11a Câmara)

Manifestou-se, também, o Supremo Tribunal Federal quanto à incompatibilidade da atenuante da confissão espontânea com a situação de flagrância:

"CONFISSÃO ESPONTÂNEA ATENUANTE. Em se tratando de situação concreta em que ocorrida a prisão em flagrante, em razão do transporte de vultuosa quantidade de droga, descabe cogitar da atenuante da confissão espontânea, no que esta última tem como objetivo colaborar com o Judiciário na elucidação da verdade real". (HC 101.861/MS, rel. Min. Marco Aurélio, 1ª T., j. em 13.04.2011)

No mesmo julgamento, manifestou-se o Min. Luiz Fux: "Eu também entendo que confissão espontânea e flagrante é contradictio in terminis, não dá para conviver; ou confessa voluntariamente ou é preso em flagrante. Não fez favor nenhum à Justiça".

Na mesma direção, precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Apelação- Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa- Pedido para que o réu possa recorrer em liberdade prejudicado pelo presente julgamento. Condenação

mantida. Apreensão de 20 porções de maconha e 61 porções de cocaína- Conjunto probatório seguro e coeso. Dosimetria fixada com rigor- Pena fixada no mínimo legal - Pedido de compensação entre confissão e reincidência- Inadmissibilidade- Confissão que sequer foi considerada na formação do convencimento do julgador- Redutor do art. 41 da Lei de Drogas- Não cabimento- Delação após prisão em flagrante com tóxico- Ausência de colaboração efetiva. Regime inicial Fechado obrigatório para réu reincidente condenado a corporal superior a quatro anos- Sentença mantida. Recurso improvido." (TJSP, AP 1501244-55.2019.8.26.0540, Rel. Des. José Vítor Teixeira de Freitas, j. 29.06.20).g.n.

"[...] Não assiste razão ao apelante quando pleiteia o benefício da atenuante da confissão espontânea, previsto no artigo 65, III, "d", do Código Penal, pois, no caso de que se trata, a confissão, além de absolutamente prescindível para o desate condenatório, em razão da solidez da prova incriminadora produzida sob o crivo do contraditório, bem revelando hábil manejo de autodefesa para tentada incidência da atenuante genérica do art. 65, III, "d", do Código Penal. Assim, por não espontânea e desacompanhada de arrependimento, não permitiria a diminuição da pena pela atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal. Nesse sentido, "espontânea é aquela confissão em que o agente, independentemente do concurso da autoridade, busca esta para admitir o delito" (Apelação nº 0001496-21.2009.8.26.0270. Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 26.6.2012). No mesmo sentido: veneranda decisão da Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Apelação nº 0052302-70.2011.8.26.0050. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 16.4.2013). Da mesma forma: STF HC. nº 101.861/MS, Rel. Exmo. Min. MARCO AURÉLIO, j. em 13.4.2011). No mesmo sentido: PROVA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA E VOLUNTÁRIA - DISTINÇÃO. "Não se pode confundir a confissão espontânea com a confissão voluntária do réu surpreendido em plena execução do delito. Esta é uma declaração movida por uma circunstância de evidência dos fatos, aquela pela mera intenção de declarar a verdade". (Apelação nº 566.425/1, Julgado em 01/02/1990, Col. 1ª Câmara, Rel.: ALBERTO MARINO. RJDTACRIM 5/169)" (TJSP; Apelação Criminal 1501404-12.2021.8.26.0540; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2022; Data de Registro: 22/02/2022). g.n.

"(...) Afasta-se o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão. Isso porque Paulo foi preso em flagrante vendendo drogas a um adolescente e outro indivíduo, de modo que sua confissão não foi utilizada para formação da convicção. O flagrante e os depoimentos das testemunhas são suficientes para sustentar sobremaneira o édito condenatório." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500902-44.2018.8.26.0616,, rel. Des. Roberto Porto, j. 18.6.2020, V.U.).g.n.

"(...) Ademais, sobreleva registrar que a referida confissão não foi utilizada pelo magistrado sentenciante como elemento de convicção, não incidindo, assim, na hipótese, a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. (...) Veja que, para o reconhecimento da finalidade mercantil da droga apreendida com o acusado, o douto juiz não utiliza de sua confissão a esse respeito, mas sim dos demais elementos de convicção colhidos." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500646-88.2020.8.26.0630, rel. Des. Camilo Léllis, j. 22.3.2022, V.U.). g.n.

Apelação criminal - Tráfico de drogas - [...] Dosimetria - pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Inteligência do art. 42 da Lei de Drogas. Na segunda fase, exasperação decorrente da reincidência. Confissão que não foi considerada na formação do convencimento do julgador. [...] Preliminar rejeitada. Recurso defensivo improvido. "[...] verificando-se que neste caso, não houve qualquer menção ao teor do interrogatório do acusado para a formação do convencimento do douto Julgador para o deslinde desta ação penal, não há como se acolher o pleito de consideração da referida atenuante de pena, nos termos dos

abalizados entendimentos jurisprudenciais referidos." (TJSP; Apelação Criminal 1500255-44.2022.8.26.0540; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/05/2022; Data de Registro: 08/05/2022).

"APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo duplamente majorado - Incidência da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo comprovada pela prova pessoal - Desnecessidade de apreensão e perícia da arma usada no roubo. (...) Impossibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porquanto não utilizada para fundamentar a condenação - Aumento único no concurso de causas de aumento de pena contemplado no parágrafo único do artigo 68 do Estatuto Penal que não constitui direito subjetivo, tratando-se de faculdade judicial, que, porém, requer justificativa sobre a fração imposta, como no caso penas e regime prisional fechados mantidos. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO." (TJSP, Apelação Criminal nº 1500106-76.2021.8.26.0348, Rel. Des. Adilson Paukoski Simoni, j. 12.04.22).

"(...) Não era o caso, outrossim, do reconhecimento da atenuante da confissão, porquanto tenha ela sido parcial (negou o apelante o emprego de arma de fogo), bem como por ser ela refratária à prisão em flagrante. Como bem destacou o MM. Juízo a quo, no decisum, "(...) Justifica-se a não incidência da atenuante da confissão, não espontânea e parcial, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão de quem foi preso em flagrante, logo após desembarcar do veículo roubado, e buscou falsear a verdade, a fim de atenuar sua responsabilidade, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos." (fls. 148). De mais a mais, ainda que fosse possível seu reconhecimento, nenhuma redução seria feita, pois, como adiantado, já foram as penas bases mantidas no mínimo legal." (TJSP; Apelação Criminal 1502696-32.2021.8.26.0540; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/06/2022; Data de Registro: 06/07/2022).

Não bastasse, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, recentemente:

"Agravamento regimental no habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Matéria não analisada na apelação. Ôbice à inovação em sede de embargos de declaração. Constrangimento ilegal inexistente, Atenuante da confissão espontânea. Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça STJ. Édito condenatório apoiado em outros elementos. Não incidência. Precedentes. Agravamento regimental desprovido. 1. [...] 2. Ainda que controverso o fato de que o paciente assumiu a autoria do delito, esse dado não foi utilizado para a formação do convencimento do julgador. Conforme se verifica, a condenação está amparada no testemunho da vítima e dos policiais condutores da prisão, sendo portanto, inviável a redução da reprimenda. Precedentes, 3. Agravamento regimental desprovido (STJ AgRG no HC 648.216/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.06.2021, DJe, 15.06.2021).g.n

"A Súmula 545/STJ prevê que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. Evidenciado que a confissão informal do réu somente foi explicitada na transcrição dos depoimentos dos policiais condutores, não tendo, todavia, sido utilizada em momento algum para embasar a condenação, sequer citada pelo magistrado sentenciante, deve ser afastada a possibilidade de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, 'd', do Código Penal" (AgRg no AREsp 1599610/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020).

Na última fase, reconhecida a tentativa, observado o iter criminis percorrido - ré surpreendida já no caixa da loja, pronta para deixar o local com as mercadorias

escondidas na bolsa - procede-se a diminuição da pena em 1/3, definindo-se a condenação em 01 ano e 02 meses de reclusão e 10 dias-multa, pena que torno definitiva.

Tratando-se de ré reincidente, incabível o privilégio do § 2º do art. 155 do Código Penal.

O valor do dia-multa é o unitário mínimo.

Fixa-se o regime intermediário para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33 do Código Penal. Regime mais brando não seria suficiente para prevenção e reprovação da conduta. Pelas mesmas razões, não se aplica nenhum benefício legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na ação penal para CONDENAR a ré REGIANE DE SOUZA, qualificada nos autos, às penas de 01 ano e 02 meses de reclusão, sob regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, no unitário mínimo, por incursão no caput do artigo 155 c/c inciso II do art. 14, ambos do Código Penal.

Faculta-se à ré apelo em liberdade, tendo em vista o decidido no habeas corpus de fls. 65-6 e no decisum de fls. 218-9.

Com o trânsito em julgado, inscreva-se o nome da ré no rol dos culpados.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella - Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 28 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA